

1502206-85.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... de drogas, onde acabou realizando o tráfico para poder adquirir mais drogas. Disse que todas as drogas apreendidas estavam relacionadas ao tráfico que estava praticando. Disse ser usuário de maconha, cocaína e crack, negando fazer uso diariamente, mas alegou ter feito uso na data dos fatos, antes de ser abordado pelos policiais. Declarou-se arrependido dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502206-85.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502206-85.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO SANTOS SANTANA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

MARCOS ROBERTO SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 61 porções de cocaína, 75 porções de maconha e quatro frascos contendo lança-perfume, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendida com o acusado a quantia de R\$50,00. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo homologada a desistência manifestada pela Defesa quanto à oitiva de uma das testemunhas indicadas em sua defesa preliminar. Ao final, foi o réu interrogado. Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público pediu a procedência da ação, para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos quanto ao apenamento, pleiteando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes relativas à calamidade pública, à reincidência e à confissão espontânea, e a não aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pediu a fixação do regime prisional fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, embora confesso, aduzindo que o acusado era dependente químico à época dos fatos, havendo dúvidas quanto à sua plena capacidade. Subsidiariamente, pediu o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, com o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Pleiteou, outrossim, pela aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito ao réu de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime descrito na denúncia. Contou que havia discutido com sua companheira, foi ao ponto de venda de drogas, onde acabou realizando o tráfico para poder adquirir mais drogas. Disse que todas as drogas apreendidas estavam relacionadas ao tráfico que estava praticando. Disse ser usuário de maconha, cocaína e crack, negando fazer uso diariamente, mas alegou ter feito uso na data dos fatos, antes de ser abordado pelos policiais. Declarou-se arrependido dos fatos.

Corroborando a confissão do réu, a testemunha policial civil Raphael Ramos Jacovani, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava ronda com seu parceiro policial Paulo por alguns pontos de tráfico já conhecidos no meio policial e, ao passar pelo local dos fatos, também conhecido pela ocorrência da mercancia ilícita de drogas, viu o acusado. Narrou que a viatura foi estacionada a cerca de 50 metros e foi realizado monitoramento, durante o qual viu um indivíduo procurar o acusado, entregar dinheiro a este e receber, de volta, algum objeto, saindo do local em sentido contrário ao da viatura. Declarou que, logo após, outro indivíduo aproximou-se do acusado e entregou dinheiro a ele. Disse que, então, o réu dirigiu-se a um terreno baldio próximo, onde abaixou-se e retirou um objeto de um saco que estava em meio a alguns materiais. Narrou que o réu retornou ao indivíduo que o aguardava, entregando a ele o objeto, e este também foi embora em sentido contrário ao da viatura, sendo inviável a abordagem. Relatou que, na sequência, foi realizada a abordagem do acusado. Consignou que, em busca pessoal, foram localizados no bolso do réu duas porções de cocaína e R\$50,00. Disse que seu parceiro Paulo foi até o terreno baldio, encontrando, no local onde o réu havia mexido, uma sacola contendo 59 porções de cocaína, além de maconha e lança-perfume. Narrou que o acusado, informalmente, admitiu a prática do crime de tráfico de drogas. Relatou que já efetuou prisões em razão do tráfico de entorpecentes naquele mesmo local em que o acusado estava. Consignou que do local onde a viatura estava, era possível ver o ponto onde o réu mexeu no terreno baldio e ali as drogas foram encontradas. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Disse que não houve apoio de outras viaturas durante esta ocorrência. Esclareceu que, em regra, em tais locais onde ocorre o tráfico de drogas, a campana somente é viabilizada se o indivíduo que estiver praticando o crime não perceber a aproximação do veículo. Narrou que, a partir da abordagem, toda a ação policial é realizada de forma rápida, pois a equipe policial, que naquela data era constituída por apenas dois agentes, é hostilizada por populares que se aproximam, não havendo como conduzir testemunhas à presença da Autoridade Policial. Declarou que o resultado do processo instaurado após as prisões em flagrantes em nada lhe beneficia ou prejudica.

A testemunha policial civil Paulo Sergio Pereira de Menezes, ouvida em Juízo, narrou que realizava diligência em viatura descaracterizada com o policial Raphael

e, ao passar pelo local dos fatos, já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, pois ali já realizou prisões em flagrante, viu o acusado em atitude suspeita, pois olhava para os lados atentamente. Relatou que a viatura foi estacionada e iniciou-se o monitoramento, durante o qual viu o réu ser procurado por um indivíduo e, após breve diálogo, receber dinheiro deste. Narrou que, ato contínuo, viu o acusado entregar algo que segurava na mão àquele indivíduo, que retirou-se do local. Declarou que o movimento típico de traficância repetiu-se quando outro indivíduo aproximou-se do acusado e entregou dinheiro a ele. Disse que o réu, então, deslocou-se a um terreno baldio, sem muro dianteiro, onde havia matos e telhas e relatou que o acusado ergueu um pedaço de telha, retirando de uma sacola que ali estava um objeto. Narrou que o réu guardou a sacola e retornou ao indivíduo que o aguardava, a quem entrou aquele objeto, tendo aquele homem se afastado rapidamente em sentido contrário ao da viatura. Consignou que, diante de todos os indícios, foi realizada a abordagem do acusado e, em busca pessoal, com ele foram encontradas duas porções de cocaína e R\$50,00 em notas trocadas. Declarou que foi rapidamente ao terreno e, no local onde o réu havia mexido, encontrou a sacola contendo 59 porções de cocaína iguais àquelas que o acusado portava, além de 75 porções de maconha e quatro frascos de lança-perfume. Disse que o réu, informalmente, admitiu a prática do crime, dizendo que estava precisando de dinheiro. Relatou que foi a primeira vez que deteve o acusado. Consignou que toda a ação policial, entre a identificação do réu como a pessoa que estava realizando o crime até sua condução à delegacia, ocorreu em trinta minutos. Disse que havia transeuntes no local, mas esclareceu que, em regra, populares alegam nada ter visto, por temerem que, com a saída da polícia do local, recebam ameaças. Declarou que apenas executa seu ofício e o resultado do processo em nada lhe beneficia. Marta Miranda Lima, ouvida como informante do Juízo, disse relacionar-se com o acusado há quatro anos e declarou que o réu faz uso de maconha e cocaína, o que ocasionava conflitos na vida do casal. Declarou que trabalha produzindo marmiteix e o acusado laborava consigo, realizando entregas, porém sempre ocorreram problemas, pois o réu, por vezes, tem recaída em seu vício ou, ainda, não retorna para casa. Contou que havia brigado com o acusado dias antes da prisão dele, porque discordava do uso de entorpecentes e do comportamento do acusado quando consumia a droga, sendo que o réu saiu de casa e, dias depois, soube ter sido ele detido. Declarou que pagava R\$30,00 ao acusado por dia, sendo que também ocorriam brigas por esta razão, pois o réu queria mais dinheiro.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais civis, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a diligência ao local dos fatos, a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes que ele trazia e também guardava.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são

aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais civis, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes, e encontram-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, corroborando a confissão do acusado quanto à prática do crime de tráfico de drogas. Embora a confissão do acusado quanto à prática do tráfico de drogas não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelo depoimento da testemunha policial em Juízo, como já destacado.

Frise-se que ambas as testemunhas asseveraram ter visualizado o acusado em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas e afirmaram que o viram ser procurado por mais de um indivíduo, perfazendo a movimentação típica da venda de entorpecentes.

As testemunhas puderam visualizar, ainda, o local de onde o acusado retirou drogas para entregar a um dos indivíduos que o procurou e consignaram ter sido ali encontrada a maior quantidade de drogas variadas, além de terem localizado na posse do réu duas porções de cocaína.

Acrescentou, ainda, a testemunha Paulo que as porções de cocaína localizadas na sacola guardada no terreno baldio eram iguais àquelas encontradas na posse do réu. Todas estas circunstâncias indicam, portanto, que todas as drogas apreendidas nos autos efetivamente pertenciam ao acusado e destinavam-se ao tráfico.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Finalmente, não há nada nos autos que indique que o acusado não fosse plenamente capaz de entendimento e autodeterminação quanto ao caráter ilícito dos fatos.

Há nos autos apenas a alegação do acusado de ser usuário de três tipos de entorpecentes e as declarações de sua companheira no mesmo sentido.

Entretanto, é de observar que o próprio acusado disse não fazer uso diário das substâncias toxicológicas e nenhuma outra circunstância demonstrou a dependência

química do acusado ou que estivesse ele privado de sua plena capacidade, na forma como aduzido pela Defesa.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, justifica-se o aumento da pena em 1/6.

Assim, fixo a pena-base, para cada acusado, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática da mesma espécie de crime, conforme certidão criminal de fls. 18, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estabelecido.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ficam as circunstâncias compensadas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade de drogas apreendidas, bem como da reincidência específica do acusado.

Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART.

33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E

OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal

Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante

ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como

atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses

de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros

estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não

configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na

primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar

superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Da mesma forma, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa. Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Ressalte-se, outrossim, que o acusado é reincidente em razão da prática do crime de tráfico de drogas, conforme já exposto, elementos estes que somados à quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, além de ser o réu reincidente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei) Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no

regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, além de ser o acusado reincidente específico. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, verifico presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 12 de setembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA